

1500141-74.2021.8.26.0400

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Breno Augusto Gonçalves Giaconello

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Breno Augusto Gonçalves Giaconello, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500141-74.2021.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500141-74.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

Breno Augusto Gonçalves Giaconello

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Breno Augusto Gonçalves Giaconello, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 158/159).

Determinou-se o processamento (fls. 160/162).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 178), apresentou resposta escrita (fls. 229/230). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 9 de setembro de 2022 (fls. 249/252) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 283).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 03/06 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 [AEA]), das imagens fotográficas dos objetos apreendidos (fls. 37 e 40/41 [IF]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 30/33) e definitivos (fls. 173/174, 290/291, 297/299, 300/303, 304/307 e 308/310 [LPTox]) e dos laudos periciais telefônicos (fls. 175/177, 191/197 e 292/294 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Marcelo Adaor Neves, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 07), que: "se encontravam em patrulhamento de rotina quando avistaram um sujeito na via pública conversando com uma pessoa no interior de um veículo Ford Fiesta que estava parado, sendo que ao perceber a aproximação da viatura o veículo deixou o local rapidamente enquanto que o rapaz saiu andando apressado com o objetivo de adentrar ao imóvel situado no endereço Rua Cândido de Lima, numeral 90, no bairro Santa Efigênia, nesta. Narram que desembarcaram rapidamente e conseguiram abordar aquele rapaz, o qual foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele, foi identificado como sendo BRENO AUGUSTO GONÇALVES GIACONELLO, o mesmo foi indagado se estava envolvido com atividade ilícita e se havia entorpecentes no interior do imóvel, ocasião em que respondeu que sim, a entrada no imóvel foi franqueada e acompanhada pelo genitor CARLOS ALBERTO GIACONELLO, o autuado BRENO indicou o local no armário dele onde havia o entorpecente maconha tendo a droga sido localizada guardada em um pequeno recipiente de vidro, oportunidade em que BRENO informou que aquela maconha era para consumo próprio dele e que era usuário, depois foi indagado se não havia mais drogas no imóvel, ele respondeu que não havia mais nada de ilícito na casa, então continuaram a procurar e encontraram dois pequenos pedaços de papel coloridos, aparentando serem pontos de LSD, após a localização dos pontos de LSD o investigado BRENO foi indagado sobre a procedência e informou que não era usuário de LSD mas confirmou tratar-se do entorpecente, continuando as buscas foram localizados mais pontos de LSD guardados na carteira, depois continuaram a procurar e acharam uma blusa que continha no bolso R\$ 6.719,00 (seis mil setecentos e dezenove reais) em dinheiro e também mais pontos de LSD em cartelas acondicionadas em um pequeno saquinho plástico, totalizando 287 pontos do entorpecente, também foram encontrados três tubinhos contendo substância líquida que aparentam ser essência para fumar Nargile, mas não sabem informar se tais substâncias possuem algum agente entorpecente em sua composição. Após a localização dos entorpecentes BRENO foi indagado sobre a droga e confessou ter adquirido os pontos de LSD em uma festa chamada TRANCE 13, em São José do Rio Preto, de pessoa desconhecida, pagou o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) por 500 (quinhentas) unidades e que vendeu cada unidade pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais), admitindo que aquele dinheiro era fruto da venda dos entorpecentes. Informa por fim que também localizaram dois telefones celulares, um deles IPHONE e outro Motorola, ambos foram arrecadados no local e apresentados nesta delegacia. Diante da situação BRENO AUGUSTO foi detido e conduzido até esta Unidade Policial ocasião em que cientificaram a Autoridade dos

fatos." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Alessandro Dameto, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 10), que: "se encontravam em patrulhamento de rotina quando avistaram um sujeito na via pública conversando com uma pessoa no interior de um veículo Ford Fiesta que estava parado, sendo que ao perceber a aproximação da viatura o veículo deixou o local rapidamente enquanto que o rapaz saiu andando apressado com o objetivo de adentrar ao imóvel situado no endereço Rua Cândido de Lima, numeral 90, no bairro Santa Efigênia, nesta. Narram que desembarcaram rapidamente e conseguiram abordar aquele rapaz, o qual foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele, foi identificado como sendo BRENO AUGUSTO GONÇALVES GIACONELLO, o mesmo foi indagado se estava envolvido com atividade ilícita e se havia entorpecentes no interior do imóvel, ocasião em que respondeu que sim, a entrada no imóvel foi franqueada e acompanhada pelo genitor CARLOS ALBERTO GIACONELLO, o autuado BRENO indicou o local no armário dele onde havia o entorpecente maconha tendo a droga sido localizada guardada em um pequeno recipiente de vidro, oportunidade em que BRENO informou que aquela maconha era para consumo próprio dele e que era usuário, depois foi indagado se não havia mais drogas no imóvel, ele respondeu que não havia mais nada de ilícito na casa, então continuaram a procurar e encontraram dois pequenos pedaços de papel coloridos, aparentando serem pontos de LSD, após a localização dos pontos de LSD o investigado BRENO foi indagado sobre a procedência e informou que não era usuário de LSD mas confirmou tratar-se do entorpecente, continuando as buscas foram localizados mais pontos de LSD guardados na carteira, depois continuaram a procurar e acharam uma blusa que continha no bolso R\$ 6.719,00 (seis mil setecentos e dezenove reais) em dinheiro e também mais pontos de LSD em cartelas acondicionadas em um pequeno saquinho plástico, totalizando 287 pontos do entorpecente, também foram encontrados três tubinhos contendo substância líquida que aparentam ser essência para fumar Nargile, mas não sabem informar se tais substâncias possuem algum agente entorpecente em sua composição. Após a localização dos entorpecentes BRENO foi indagado sobre a droga e confessou ter adquirido os pontos de LSD em uma festa chamada TRANCE 13, em São José do Rio Preto, de pessoa desconhecida, pagou o valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) por 500 (quinhentas) unidades e que vendeu cada unidade pelo valor de R\$ 10,00 (dez reais), admitindo que aquele dinheiro era fruto da venda dos entorpecentes. Informa por fim que também localizaram dois telefones celulares, um deles IPHONE e outro Motorola, ambos foram arrecadados no local e apresentados nesta delegacia. Diante da situação BRENO AUGUSTO foi detido e conduzido até esta Unidade Policial ocasião em que cientificaram a Autoridade dos fatos." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O informante Carlos Alberto Giaconello, que é pai do acusado, declarou, perante a autoridade policial (fls. 09), que: "reside no mesmo endereço que o filho na Rua Candido de Souza Lima, 90, bairro Santa Efigênia, nesta; Que, indagado sobre os fatos informou que no momento da abordagem não se fazia presente no imóvel, chegou logo depois e foi informado pelos policiais que já tinham começado os procedimentos de busca no imóvel após a permissão de sua esposa CELIA BATISTA TIBERIO, então o depoente chegou a tempo de acompanhar o procedimento de busca no quarto de BRENO, presenciou o momento em que os policiais encontraram a maconha no guarda roupas do quarto dele, também confirma que os pontos de LSD foram encontrados no guarda roupas de seu filho BRENO; Que, o dinheiro também foi localizado no guarda roupas em um bolso de uma peça de roupas; Que, o depoente não tinha conhecimento de que BRENO estava usando maconha; Que, sabia que ele já tinha usado quando menor de idade; Que, nunca tinha visto os entorpecentes LSD e não conhecia o tipo de entorpecente, também não presenciou BRENO usando maconha ou guardando erva na residência; Que, indagado sobre o valor encontrado com BRENO informa que ele foi recebido em caráter de pensão por conta da falecida genitora de BRENO; Que, esse dinheiro é sacado pelo depoente e entregue para BRENO pois pertence a ele; Que, BRENO não está trabalhando, terminou o ensino médio; Que, o depoente não fica na residência pois trabalha o dia todo; Que, BRENO fica com a irmã de dez anos e a

atual companheira do depoente; Que, o depoente nunca percebeu nenhuma movimentação suspeita no imóvel; Que, o depoente esclarece que BRENO sai a noite porém não sabe onde ele vai." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Sandra Aparecida de Barros Souza, que é conhecida do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

A testemunha Zenon Viana da Silva, que é conhecido do acusado, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em síntese, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do acusado."

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 11).

Confirmou a prática criminosa.

A oitiva foi assistida por Advogado.

Confessou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava nas proximidades da sua casa, quando, ao adentrar o domicílio, foi abordado por membros da Polícia Militar. Questionado, era viciado em drogas. A sua madrastra autorizou a busca domiciliar. De fato, guardava, para consumos pessoal e alheio, drogas. As drogas foram localizadas e apreendidas pelos agentes do Estado. Utilizava-se de aplicativo de mensagens de aparelho telefônico celular a fim de contatar possíveis consumidores. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

2.1.1Do tráfico ilícito de drogas

Nos termos do art. 33, caput, da LD, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo penal, vejam, é "importar" (fazer vir; trazer, introduzir mercadorias de outro País), "exportar" (enviar, remeter, vender para fora do País ou do Estado), "remeter" (mandar; enviar; recomendar; fazer entrega; expedir; encaminhar; destinar), "preparar" (aprontar; arranjar; obter [um corpo qualquer] por meio de composição ou decomposição; compor; dosear; urdir; maquinar; pôr em condições de servir; predispor), "produzir" (dar origem a; causar; fabricar), "fabricar" (produzir na fábrica; manufaturar, preparar; inventar; engendrar), "adquirir" (obter; comprar; aquisitar), "vender" (alienar; ceder por certo preço; trocar por dinheiro; negociar; não conceder gratuitamente; sacrificar por dinheiro ou por interesse; entregar mediante remuneração; dispor do que possui a troco de dinheiro), "expor à venda" (apresentar; mostrar), "oferecer" (dar; facultar; levar à presença de; mostrar), "ter em depósito" (pôr em depósito; armazenar; guardar [em lugar seguro]; dar a guardar temporariamente), "transportar" (conduzir; levar de um lugar para outro; enlevar; arrebatado; transpor), "trazer consigo" (conduzir ou transportar para cá; fazer-se acompanhar), "guardar" (vigiar; vigilar; conservar; manter), "prescrever" (receitar; ministrar), "ministrar" (prestar; fornecer; aplicar), "entregar" (dar; ceder; confiar) "a consumo" (elemento subjetivo específico [pela interpretação contextual]) ou "fornecer" (promover; abastecer; garantir; ministrar; proporcionar ou ministrar o necessário a) "drogas" (as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em

lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União [art. 2º da LD]), "ainda que gratuitamente" (animus sine lucro captando), "sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (elemento normativo).

A redação do art. 33, caput, da LD, diferentemente do disposto nos arts. 28, caput (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), e 33, § 1º, III (utilização ilícita de bem para o tráfico ilícito de drogas ou com o seu consentimento), da LD, não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 4.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. BACILA, Carlos Roberto; RANGEL, Paulo. Comentários penais e processuais penais à lei de drogas. – 1.ª edição – Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2007. MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Legislação penal especial. 7.ª edição – São Paulo: Atlas, 2004. MARCÃO, Renato. Tóxicos: lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 – nova lei de drogas. – 4.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio de. Lei antidrogas anotada – comentários à lei n. 11.343/2006. – 9.ª edição – São Paulo: Saraiva, 2009. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice, CUNHA, Rogério Sanches, OLIVEIRA, William Terra de. Lei de drogas comentada. 3.ª edição – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008), referendado pela jurisprudência (STF – Primeira Turma – Habeas Corpus 69.806-GO – Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 03; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 – Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO – ACrim. n. 33578-9/213 – Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), de que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, exige-se a vontade de participar da produção e da circulação de drogas (a intenção de comercializar drogas ilícitas).

Não se exige, todavia, a exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Por se tratar de infração permanente (TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500168-08.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.M., j. 18/04/2022, p. 03/04), entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 313 do CPP).

Das dezoito condutas descritas no art. 33, caput, da LD (tráfico ilícito de drogas), o art. 28, caput, da LD (porte ilícito de drogas para consumo pessoal) descreve cinco idênticas (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal (art. 28, caput, da LD), ou alheio (art. 33, caput, da LD), o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de

drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106 [ênfatizei]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08; STJ – Quinta Turma – AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 14/06/2022 ["Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese."]), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscrias pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 – Anexo Lista E, item 1 (CANNABIS SATIVUM [planta que pode originar substância entorpecente ou psicotrópica], conhecida popularmente por maconha) e Anexo Lista F2 (25B-NBOH e 25C-NBOH [substâncias psicotrópicas], conhecidas popularmente por N-bomb ou Smiles [drogas sintéticas]).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Ademais, quanto ao valor significativo apreendido (AEA), o acusado, posto (apesar de) alegar que seria fruto da pensão por morte (fato impeditivo e extintivo do direito do autor da ação penal), não comprovou tal fato (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501795-67.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CAMILLO LÉLLIS DOS SANTOS ALMEIDA, V.U., j. 08/11/2021, p. 08 ["... isso se dá, justamente, pelo fato de tal

importância advir da origem espúria, sobretudo em se tratando de cédulas baixas, provenientes de diversas vendas anteriores."]).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 10/11; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 11; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500422-78.2020.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAERTE MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, V.U., j. 02/06/2022, p. 15; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500639-10.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO SALE JÚNIOR, V.M., j. 15/06/2022, p. 15/17), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

Eis o meu convencimento.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável).

Sem ordem não há progresso.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 275/279), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas e (iv) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 4/6 (quatro sextos), em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênua, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04, respectivamente; TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501167-78.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 08/04/2022, p. 10; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia -

Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500017-62.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 11/04/2022, p. 18/19; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto - Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04 ["A exasperação, calcada no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), se deu mediante fundamentação concreta e idônea, com esteio em dados que exorbitam os limites inerentes ao tipo penal..."]; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500636-21.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª ELY AMIOKA, V.U., j. 22/06/2022, p. 12; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500770-82.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª FÁTIMA GOMES, V.U., j. 31/03/2022, p. 10/11; TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP - 15ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara

Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Em apertadíssima síntese, os vários julgados mencionados posicionam-se no mesmo sentido, isto é, a circunstância considerada observa o art. 59 do CP e o art. 42 da LD.

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga sintética apreendida (LPTox [as drogas sintéticas, sob a forma de selos, pó ou comprimidos, apresentam estrutura molecular e efeitos similares aos de outras já conhecidas e proibidas, como os alucinógenos LSD e NBOMe – também conhecido como N-bomb ou Smiles]), cujo alto potencial para uso abusivo representa risco à saúde dos usuários.

Da quantidade das drogas: No entender deste magistrado, a apreensão de expressiva (significativa) quantidade de drogas deve ser considerada (STJ – Habeas Corpus n. 688.099-SP, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Min. MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, j. 11/03/2022, p. 05; STJ – Quinta Turma – Habeas Corpus 409.324/MS – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Dje 28/11/2017; TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Pres. Rel. Des. PÉRICLES DE TOLEDO PIZA JÚNIOR, V.U., j. 12/08/2019, p. 14; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501484-76.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 11/05/2022, p. 14; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 – Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003223-66.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TRISTÃO RIBEIRO, V.U., j. 5/07/2018; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500166-87.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FARTO SALLES, V.U., j. 09/06/2022, p. 05/06; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003192-75.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 7; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 5; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500631-96.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.U., j. 08/08/2022, p. 04; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 10; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500647-84.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, V.U., j. 05/07/2022, p. 12; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002061-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DA SILVA, V.U., j. 03/10/2019, p. 07).

Das circunstâncias do crime: No entender deste magistrado, o meio de execução empregado pela parte ré há de ser levado em conta, ou seja, a utilização de aplicativo de aparelho telefônico celular (e.g., mensagens de celular, e-mail, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram ou qualquer rede social), que, pela aproximação virtual de pessoas, facilita, agiliza e dissemina o ato de mercenciar (compra e venda) a droga (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500036-97.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 26/04/2022, p. 07/08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500583-11.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a FÁTIMA VILAS BOAS CRUZ, V.U., j. 19/08/2022, p. 14; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501397-86.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, V.M., j. 18/01/2022, p. 05 ["E as circunstâncias do delito foram fundamentadas pelo fato de o apelante fazer uso de redes sociais e aplicativos de conversa em seu aparelho celular para a prática da traficância, o que facilita, agiliza e dissemina a mercancia ilícita."]; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000179-82.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR, V.U., j. 08/04/2021, p. 22 ["Motivação conveniente."]; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500489-29.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 25/03/2022, p. 12 e 16; TJSP – 12ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500012-54.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. [sorteado] Des. PAULO ANTONIO ROSSI [vencido], V.M., j. 03/05/2022, p. 57/58 ["De fato não se pode comparar como circunstâncias normais a facilidade desenvolvida por esta sistemática em comparação daquela comumente desempenhada por traficante que fica na rua aguardando o consumidor chegar."]).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 18/21 [Boletim de Identificação Criminal]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ) e confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada a segunda circunstância com a terceira (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502532-07.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ FERNANDO VAGGIONE, V.U., j. 13/01/2021, p. 05; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002081-90.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 23/10/2020, p. 10; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000568-38.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 30/01/2019, p. 05; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000105-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CARDOSO PERPÉTUO, V.U., j. 14/02/2019, p. 06; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018), fixo a pena provisória, com atenuação de 1/3 (um terço), em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância atenuante da jovialidade – a qual se refere à personalidade do agente, no entender deste magistrado – é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 16ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação n. 1500451-65.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 02/02/2021, p. 09 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço o preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais, quais sejam: ser primária e de bons antecedentes (requisitos positivos), não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa (requisitos negativos) (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Não existe prova suficiente de que a parte ré dedica-se às atividades criminosas ou integra organização criminosa (indicação segura), cujos argumentos do autor da ação penal não são concretos (palpáveis).

De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 209.023/MG – Rel.^a Min.^a CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, j. 19/11/2021, p. 08), com o qual concordo, a utilização da natureza e da quantidade da droga (substância ou produto) na primeira fase e na terceira fase da fixação das penas, para definir o percentual da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, caracterizaria o bis in idem.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4 Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500483-90.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 18/01/2021, p. 11), porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002372-56.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 02/05/2020, p. 07), o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF).

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da

LEP) (TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal